

1525331-90.2019.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/09/2022

...

"Flagrante preparado - ocorrência - tráfico de drogas - indução do apelado ao tráfico pelos policiais - caracterização de crime impossível - venda que jamais seria terminada" Súm. 145 do STF" (TJSP, Ap. 129.500-3, Rel. Celso Limongi)

"Prisão - Flagrante preparado - ocorrência - tráfico - uso próprio - instigação do investigação para aquisição da droga - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1525331-90.2019.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1525331-90.2019.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2242291/2019 - DEL.SEC.4ª NORTE, 6945628 - DEL.SEC.4ª NORTE, 131/19/100 - DEL.SEC.4ª NORTE, 2242291 - DEL.SEC.4ª NORTE, 131/19/100 - DEL.SEC.4ª NORTE, 2242291 - DEL.SEC.4ª NORTE, 131/19/100 - DEL.SEC.4ª NORTE, 2242291 - DEL.SEC.4ª NORTE, 131/19/100 - DEL.SEC.4ª NORTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE NICACIO DE OLIVEIRA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

JOSÉ INACIO DE OLIVEIRA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06, porque, supostamente, em 20

de agosto de 2019, às 16:00 h, nesta Capital, no Bairro Freguesia do Ó, na Avenida Otaviano Alves de Lima, altura do número 3.600, trazia com ele, para fins de entrega a consumo de terceiros, e expôs à venda, drogas (cocaína) sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Em 30 de agosto de 2019, a denúncia foi recebida, determinando-se a citação do acusado.

Por intermédio da Defensoria Pública, foi apresentada resposta à acusação (fls. 73).

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas, prejudicado o interrogatório diante da revelia do réu

Ao final, o d. representante do Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia (fls. 127/128). Já a d. Defesa requereu a absolvição do acusado, formulando pedidos subsidiários (fls. 138/144).

É o relatório.
Fundamento e Decido.

A ação penal é improcedente, eis que se trata de crime impossível.

De acordo com a prova oral produzida em juízo, o policial civil Fabiano Aparecido Gasparotto, passando-se por usuário de drogas, pediu cocaína ao réu, que lhe forneceu um papelote de cocaína por R\$ 10,00. Com o acusado, havia 11 invólucros de cocaína e a quantia de R\$ 10,00.

A versão de Fabiano foi corroborada pelo policial civil Marcello Barroso Soubihe, seu colega de trabalho.

Com o devido respeito e sem desmerecer o justo e honesto trabalho de ninguém, a sociedade espera mais da polícia judiciária do que a atitude de agentes que, sem campana ou trabalho investigativo prévios, passando-se por usuários, passem a prender supostos pequenos traficantes ou usuários que, para sustentarem o próprio vício, fornecem drogas a quem lhes solicite.

O traço caracterizador de crime impossível no presente caso é a ausência de prévia campana ou investigação, na esteira da jurisprudência do Col. STJ sobre o tema:

"In casu, já havia notícia do exercício da traficância pelo sentenciado, a partir da qual originou-se uma investigação prévia, que levou à operação resultante da prisão em flagrante" (AgRg no HC n. 565.902/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020)

De acordo com a Súmula 145 do STF, "não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação".

O policial, ao simplesmente se passar por usuário, tornou a consumação do crime impossível, tratando-se de flagrante preparado, mormente em razão da pouca quantidade de droga apreendida em poder do réu (11 papelotes) e parca quantia em dinheiro (R\$ 10,00).

Em verdade, a partir da prova produzida em juízo, não é possível asseverar, com certeza, que se tratava o réu de traficante ou de usuário que aceitou fornecer parte da droga que consigo trazia.

Não se pode olvidar que a substância tóxica só foi apresentada, com a finalidade de venda, em decorrência da provocação engendrada pelo policial disfarçado, tratando-

se, portanto, de vontade viciada.

Há, assim, indução a erro, sendo certo que o agente provocado somente revelou sua situação por estar atuando sob o engano do provocador.

O artigo 17 do Código Penal estatui que não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.

Nesse sentido é o magistério de Aury Lopes Júnior, citando caso similar: "o flagrante provocado também é ilegal e ocorre quando existe uma indução, um estímulo para que o agente cometa um delito exatamente para ser preso. Trata-se daquilo que o Direito Penal chama de delito putativo por obra do agente provocador. BITENCOURT explica que tudo não passa de uma cilada, uma encenação teatral, em que o agente é impelido à prática de um delito por um agente provocador, normalmente um policial ou alguém a seu serviço. É o clássico exemplo do policial que, se fazendo passar por usuário induz alguém a vender-lhe a substância entorpecente para, a partir do resultado desse estímulo, realizar uma prisão em flagrante (que será ilegal). É uma provocação meticulosamente engendrada para fazer nascer em alguém a intenção, viciada, de praticar um delito, com o fim de prendê-lo" (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional, v. II. 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 82).

A propósito, confira-se a jurisprudência:

"Flagrante preparado - ocorrência - tráfico de drogas - indução do apelado ao tráfico pelos policiais - caracterização de crime impossível - venda que jamais seria terminada" Súm. 145 do STF" (TJSP, Ap. 129.500-3, Rel. Celso Limongi)

"Prisão - Flagrante preparado - ocorrência - tráfico - uso próprio - instigação do investigador para aquisição da droga - consumação impossível - absolvição - recurso provido" (TJSP, Ap. 147.227-3, Rel. Dante Busana)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva para absolver o acusado JOSÉ INACIO DE OLIVEIRA SILVA, qualificado nos autos, com fulcro no artigo 386, III, do Código de Processo Penal, da prática do delito de tráfico que lhe foi imputado pela denúncia ministerial, pois o fato narrado não constitui infração penal.

Determino a incineração da droga apreendida, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06.

Em 30 dias, não havendo requerimento do réu de levantar a quantia apreendida, ficará esta revertida ao Fundo Penitenciário.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.I.C.

São Paulo, 02 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA